

刑事訴訟法

No.133

予備独自問題 H29-18

(配点: 3)

月 日

月 日

検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次のアからオまでの各記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を、肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。

- ア. 実体的真実の発見という刑事訴訟法の趣旨に反する。
- イ. 検察官には、起訴、不起訴の裁量権が認められている。
- ウ. 裁判所の訴因変更命令には形成力はないとされている。
- エ. 刑事訴訟法は当事者主義に立ち、訴因制度を採用している。
- オ. 被告人に利益になる場合も多い。

ア 肯定説の論拠になり得ない

実体的真実の発見という刑事訴訟法の趣旨を貫徹するなら、一罪すべてを起訴すべきであるから、本記述は肯定説の論拠になり得ない。

否定説は、検察官に一罪の一部起訴を認めると、訴因制度の下では、裁判所の審判の範囲もそれに限定されてしまうため、実体的真実発見の要請に反する結果になること等を理由とする。これに対して、肯定説は、当事者主義の下では、裁判所の任務は検察官が示した訴因の範囲内での真実発見にあるべきであり、他方、検察官には、起訴便宜・変更主義の下で、そもそも事件自体について公訴を提起・維持するか否かを判断する裁量が委ねられているのであるから、一罪の一部起訴も許されると反論する。

イ 肯定説の論拠になり得る

検察官に起訴、不起訴の裁量権が認められているとするなら、一罪の一部起訴も許容されることができると考え、本記述は肯定説の立場からの論拠となり得る。

検察官は、捜査で収集された証拠を検討し、事件を起訴するか不起訴とするかの専権を有する（247条・248条参照）。そして、一罪の一部起訴はこのような検察官の不起訴裁量権限の合理的な行使の一態様とみることができる。

ウ 肯定説の論拠になり得る

裁判所の訴因変更命令には形成力はないとするなら、検察官の審判対象設定権限に介入できないことになり、一罪の一部起訴も許容されと考えることができるため、本記述は肯定説の立場からの論拠となり得る。

判例は、訴因変更命令について、「検察官が裁判所の訴因変更命令に従わないのに、裁判所の訴因変更命令により訴因が変更されたものとする……ような効力を認めることは到底できない」としている（最大判昭40.4.28、百選A20事件）。訴因変更命令に形成力がないということは、裁判所が検察官の審判対象設定権限に介入することができないということであり、結局、検察官の不起訴裁量権限の行使が許されるということになる。

エ 肯定説の論拠になり得る

刑事訴訟法は当事者主義に立ち、訴因制度を採用しているとするなら、訴因をどのように設定するかは検察官の自由であり、一罪の一部起訴も許容されと考えることができるため、本記述は肯定説の立場からの論拠となり得る。

現行刑事訴訟法は当事者主義を採用しており、刑事訴訟における審理・判決の対象を設定する権限は検察官にあり、検察官が裁判所に対して審判を求める具体的な主張内容、すなわち訴因のみが裁判所の審理対象となる。そのため、訴因の追加・変更がされない限り、裁判所は検察官が訴因に含めていない事実を審理できず、単一の公訴事実も訴因とそれ以外の部分に分割されることになる。よって、当事者主義・訴因制度の下では、犯罪事実のどの部分を起訴するかという点が検察官に委ねられるため、検察官の不起訴裁量権限の行使が許されるといえる。

オ 肯定説の論拠になり得る

強盗を恐喝で起訴する場合のように法条競合の関係にある犯罪のうち軽いほうの罪で起訴したり、既遂を未遂として起訴したりする場合等、一罪の一部起訴を認めることにより被告人の利益となる場合も多いため、本記述は肯定説の立場からの論拠となり得る。